

1501141-77.2021.8.26.0540

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Paulo Antonio Canali Campanella

Comarca: Mauá

Foro: Foro de Mauá

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 14/12/2022

... a outro processo pela prática do crime de tráfico (cert. fl. 33 -proc 1500734-71.2021).

Nessa linha, posiciona-se o e. Superior Tribunal de Justiça:

"CONSTITUCIONAL. PENAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO EM SUBSTITUIÇÃO A RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO DE DROGAS. RECONHECIMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO "TRÁFICO PRIVILEGIADO (LEI N. 11.343/2006, ART. 33, § 4º). ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Mauá

Foro de Mauá

2ª Vara Criminal

Av. João Ramalho, 111, Mauá - SP - cep 09371-901

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1501141-77.2021.8.26.0540 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501141-77.2021.8.26.0540

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

NAYARA LIMA SENA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Paulo Antonio Canali Campanella

Vistos.

NAYARA LIMA SENA foi denunciada por incursão no caput do art. 33 da Lei nº 11.343/06.

Narra a denúncia que no dia 19 de maio de 2021, por volta das 10 horas, na Rua Fernando Colombo, 10 Viela - 143-A -Jardim Salgueiro, nesta cidade e comarca de Mauá, a acusada, trazia consigo, guardava e expunha à venda, para entrega a consumo de terceiros, 10 porções de Cannabis Sativa L., droga popularmente conhecida por maconha, 09 porções de cocaína e 12 porções de cocaína na forma de crack, drogas

ilícitas que causam dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, conforme auto de exibição e apreensão de fls. 8-9, laudo de constatação de fls. 11-3 e laudo de exame químico-toxicológico de fls. 66-8.

Recebida a denúncia, a ré foi citada (fl.175) e apresentou resposta à acusação (fls. 177-8).

Citada pessoalmente a ré (fl.175), levanta-se a suspensão do processo (fls.141-2).

Durante a instrução, a testemunha arrolada pelas partes foi devidamente inquirida. Por fim, interrogou-se a ré.

Em memoriais, pleiteia o Ministério Público a procedência da ação, enquanto a Defesa requer a nulidade da instrução por inobservância ao procedimento relativo ao acordo de não persecução penal. No mérito, pugna pela absolvição por insuficiência probatória ou, ao menos, a aplicação da pena nos patamares mínimos, com o reconhecimento da atenuante da confissão, da menoridade relativa e do tráfico privilegiado, a fixação de regime penitenciário inicial aberto, bem como a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

É a síntese do necessário.
Fundamento e decido.

Em que pese a ausência de pedido expresso da Defesa acerca de proposta de acordo de não persecução penal pelo Ministério Público, o Promotor de Justiça recusou referida benesse no oferecimento da denúncia (fls.76-81).

Destaca-se, inicialmente, que o acordo não é direito subjetivo do réu, mas ato discricionário do Promotor de Justiça.

Mais, o pedido não encontra respaldo legal, ausente requisito objetivo. Nos termos do art. 28-A do CPP, o acordo de não persecução penal é cabível apenas nas infrações penais praticadas sem violência ou grave ameaça e com pena mínima inferior a 4 anos, o que não se aplica ao caso concreto.

Neste sentido o e. Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTE. PENA MÍNIMA SUPERIOR A 4 ANOS. AUSÊNCIA DE REQUISITO OBJETIVO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. É incabível o oferecimento de acordo de não persecução penal pelo Ministério Público nos casos de tráfico ilícito de entorpecentes, cuja pena mínima é superior a 4 anos, em razão do não preenchimento de um dos requisitos objetivos do art. 28-A, caput, do CPP. 2. Agravo regimental desprovido.”(AgRg no HC 584807 / SP, Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, 13/10/2020).

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGADA NULIDADE POR AUSÊNCIA DE ENVIO DOS AUTOS AO PARQUET PARA OFERTA DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. DELITO COM PENA MÍNIMA SUPERIOR A QUATRO ANOS DE RECLUSÃO. NORMA DE CUNHO PROCESSUAL. TEMPUS REGIT ACTUM. PRECEDENTES. INVIABILIDADE DE PROPOSTA DE ANPP APÓS O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. DOSIMETRIA. AUMENTO DA FRAÇÃO DE REDUÇÃO PELO TRÁFICO PRIVILEGIADO. INVIABILIDADE. EXPRESSIVA QUANTIDADE E NATUREZA DO ENTORPECENTE APREENDIDO. PRECEDENTES. ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL E SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR MEDIDAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. EXPRESSA PREVISÃO LEGAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. - A ausência de remessa dos autos ao Parquet para oferecimento de acordo de não persecução penal não foi submetida à apreciação e, tampouco analisada pela Corte paulista, tratando-se, portanto, de matéria nova, somente ventilada neste mandamus, não sendo possível sua análise diretamente por esta Corte Superior, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes. -

Não obstante isso, verifica-se, de plano, o não preenchimento de um dos requisitos exigidos para a propositura do acordo, porquanto apesar de o delito de tráfico de drogas ser daqueles cometidos sem violência ou grave ameaça à pessoa, ele conta com uma pena mínima de 5 anos de reclusão. - Ademais, não é possível a aplicação do acordo de não persecução penal previsto no art. 28-A do Código de Processo Penal após o recebimento da denúncia, em respeito ao princípio do tempus regit actum, consignado no art. 2º do Código de Processo Penal. Desse modo, apesar de o acórdão de apelação que confirmou a condenação do paciente, haver sido proferido em 20/3/2019, quando já estava em vigor a Lei n. 13.964/2019 (23/1/2020), a denúncia contra ele já havia sido recebida, tanto é assim, que houve sentença condenatória exarada em 20/11/2018. Precedentes. - A legislação brasileira não prevê um percentual fixo para o aumento da pena-base em razão do reconhecimento das circunstâncias judiciais desfavoráveis, tampouco em razão de circunstância agravante ou atenuante, cabendo ao julgador, dentro do seu livre convencimento motivado, sopesar as circunstâncias do caso concreto e quantificar a pena, observados os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. - A expressiva quantidade e natureza especialmente deletéria do entorpecente apreendido - 980 gramas de cocaína -, justificam a fração de redução no piso legal de 1/6, nos termos do art. 42, da Lei n. 11.343/2006, haja vista que, na ausência de indicação pelo legislador das balizas para o quantum da redução aludida, a natureza e a quantidade de droga apreendida, assim como as demais circunstâncias do art. 59 do CP, podem ser utilizadas na definição de tal índice. Precedentes. - Inalterado o montante da sanção (4 anos e 2 meses de reclusão), ficam mantidos o regime inicial semiaberto e a negativa de substituição da pena privativa de liberdade por medidas restritivas de direitos por imperativo legal, nos termos do art. 33, § 2º, "b", e do art. 44, I, ambos do Código Penal. - Agravo regimental não provido." (AgRg no HC 593412 / SP, Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, 23/02/2021)

"PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. APLICAÇÃO DO ART. 28-A DO CPP. IMPOSSIBILIDADE. PECULIARIDADE DO CASO. RECONHECIMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Segundo o § 1º do art. 28-A do Código de Processo Penal, para aferição da pena mínima cominada ao delito a que se refere o caput deste artigo, serão consideradas as causas de aumento e diminuição aplicáveis ao caso concreto. 2. Para serem consideradas as causas de aumento e diminuição, para aplicação do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), essas devem estar descritas na denúncia, que, no presente caso, inexistiu, não sendo possível considerar, no cálculo da pena mínima cominada ao crime imputado ao acusado, a causa de diminuição reconhecida apenas quando do julgamento do recurso especial. No caso do delito de tráfico, far-se-á necessário o curso da ação penal, em regra, para aferir os requisitos previstos no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06, o que obsta a aplicação do benefício, que decorre, inclusive do tratamento constitucional e da lei que são rigorosos na repressão contra o tráfico de drogas, crime grave, que assola o país, merecendo um maior rigor estatal. 3. Mostra-se incompatível com o propósito do instituto do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) quando já recebida a denúncia e já encerrada a prestação jurisdicional na instância ordinária, com a condenação do acusado, cuja causa de diminuição do art. 33, §4º, da Lei de drogas fora reconhecida somente neste STJ, com a manutenção da condenação. 4. Embargos de declaração rejeitados.

Ainda, o e. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

"Contudo, a despeito da argumentação defensiva, não há de ser reconhecida qualquer irregularidade ou ilegalidade quanto a recusa, pelo Ministério Público, de propositura de acordo de não persecução penal, tão menos na ausência de remessa dos autos à Procuradoria Geral de Justiça, e isto em razão da patente inadmissibilidade diante da matéria tratada na presente ação penal, quer seja, o tráfico de entorpecentes, cuja pena mínima supera o patamar de 4 (quatro) anos, incompatível, portanto, com a medida, diante do não preenchimento de um dos requisitos objetivos

do artigo 28-A, caput, do Código de Processo Penal, necessário a tanto".(Apelação Criminal nº 1502130-83.2021.8.26.0540, TOLOZA NETO, j. 21 de março de 2022)

"Habeas Corpus. Tráfico de drogas. Alegação de quebra da cadeia de custódia. Inocorrência. Concessão de liberdade provisória. Inadmissibilidade. Decisão bem fundamentada. Presença de indícios de autoria e prova da existência dos crimes. Necessidade da custódia para garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e assegurar a aplicação da lei penal. Pacientes que ostentam ficha criminal, sendo reincidente específico, fato que revela seu desajuste na vida em liberdade e dá a exata medida do grau de periculosidade de que são possuidores. Medidas cautelares diversas da prisão que se mostram insuficientes no caso. Incabível a aplicação, desde logo, das diretrizes firmadas pelo C. STJ, no HC coletivo 596.603, porque o reconhecimento do tráfico privilegiado depende de aprofundado cotejo de provas, compatível apenas com o juízo exauriente da sentença penal. Oferecimento de acordo de não persecução penal (ANPP) que constitui faculdade do Parquet e é previsto na lei processual adjetiva para delitos com pena mínima inferior a 4 anos Inaplicabilidade, in casu, das medidas constantes da Recomendação 62 do C. CNJ. Constrangimento ilegal não caracterizado. Ordem denegada." (Habeas Corpus Criminal nº 2060179-31.2021.8.26.0000, SÉRGIO COELHO, 30 de abril de 2021)

"APELAÇÃO CRIMINAL Tráfico de entorpecentes - acordo de não persecução penal pena mínima maior que 4 anos - preliminares afastadas Autoria e materialidade delitiva comprovadas pena mantida regime aberto e pena privativa de liberdade substituída recurso da defesa provido em parte." (Apelação Criminal nº 1500547-97.2020.8.26.0540, ALBERTO ANDERSON FILHO, 3 de maio de 2021).

Além disso, o Enunciado 22 do Conselho Nacional de Procuradores-Gerais dos Ministérios Públicos dos Estados e da União impossibilita o acordo no crime de tráfico de drogas: "veda-se o acordo de não persecução penal aos crimes praticados no âmbito de violência doméstica ou familiar, ou praticados contra a mulher por razões da condição de sexo feminino, bem como aos crimes hediondos e equiparados, pois em relação a estes o acordo não é suficiente para a reprovação e prevenção do crime".

Nem se alegue ser o tráfico privilegiado quando sequer iniciou-se a produção da prova.

Desse modo, diante da notória posição institucional do Ministério Público de São Paulo e da ausência de requisito essencial para o oferecimento do benefício, não há prejuízo à Defesa pela não remessa ao Procurador Geral de Justiça.

Neste sentido o e. Tribunal de Justiça de São Paulo:

"Quanto ao tema relativo ao não envio à Procuradoria Geral de Justiça diante da recusa de oferecimento de Acordo de Não Persecução Penal pelo Ministério Público, há de se ressaltar a já mencionada inadmissibilidade para sua efetivação diante da ausência do requisito objetivo da pena mínima inferior a 4 (quatro) anos". (Apelação Criminal nº 1502130-83.2021.8.26.0540, TOLOZA NETO, j. 21 de março de 2022)

"Isto porque, respeitando entendimento diverso, é dos autos que, não houve recusa ao oferecimento de proposta de não persecução penal e sim, a impossibilidade daquela, diante das peculiaridades do fato concreto. A decisão que indeferiu a remessa dos autos à PGJ restou muito bem fundamentada, não padecendo de qualquer irregularidade ou nulidade passível de reforma (fls. 125/126), notadamente levando-se em conta a quantidade do entorpecente apreendido (149 porções de cocaína), o que leva a crer a princípio, não se tratar de tráfico privilegiado. Cabe salientar que o acordo de não persecução penal foi recepcionado pela Lei nº 13.964/2019 e poderá ser ofertado pelo Ministério Público, discricionariamente, desde que estejam

previstos os requisitos do art. 28 A do Código de Processo Penal, o que não é o caso dos autos, posto que os pacientes não confessaram a prática delitiva, um dos requisitos autorizadores do pretendido benefício conforme se depreende dos termos de interrogatórios acostados a fls. 14/15, havendo o Parquet agido de forma irrepreensível quanto aos motivos elencados ao não formular a eles, a pretendida proposta de não persecução penal (fls. 106/109), de sorte que desnecessária a remessa dos autos à Procuradoria Geral de Justiça. Cabe salientar que o Ministério Público é, antes de tudo, o defensor da ordem jurídica (artigo 127, da Constituição Federal), o fiscal da lei, numa expressão recorrente, sendo certo que o elevado ministério confiado pela Constituição Federal à Instituição é público, ou seja, traduz-se na incumbência de advogar no interesse de toda a coletividade. Nem seria preciso destacar que à sociedade interessa, tão somente, o fiel cumprimento da lei, que inclui, de um lado, o respeito ao jus puniendi estatal, nos limites estabelecidos pelas normas penais, e de outro lado, em não menor medida, a salvaguarda dos direitos e garantias individuais do acusado. Assim, diante da inexistência de constrangimento ilegal a ser reparado, DENEGO A ORDEM pleiteada.” (TJSP, Habeas Corpus Criminal nº 2072332-33.2020.8.26.0000, WALTER DA SILVA, 29 de maio de 2020).

“Apelação Criminal Tráfico Ilícito de Entorpecentes. PRELIMINAR Nulidade - Representante da acusação que deixou de ofertar acordo de não persecução penal Não preenchimento dos requisitos legais - Preliminar rejeitada. PENAS Pena-base acima do mínimo legal Atenuante de confissão espontânea não reconhecida por não ter sido integral Impossibilidade de reconhecimento das causas de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, e no art. 41, ambos da Lei nº 11.343/06 Regime inicial fechado o único adequado - Impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos ou concessão de “sursis”. PRELIMINAR REJEITADA, RECURSO DESPROVIDO.” (Apelação Criminal nº 1501074-49.2020.8.26.0540, MACHADO DE ANDRADE, 14 de abril de 2021.)

“Agravamento Regimento Pedido de suspensão do andamento da persecução penal e remessa dos autos à Procuradoria Geral de Justiça - IMPOSSIBILIDADE Carência de interesse de agir Delito de tráfico de drogas, não passível de ANPP Redação do artigo invocado suspenso (art. 28-A, §14, do CPP) Agravamento não provido.” (Agravamento Regimento Criminal nº 2041711-53.2020.8.26.0000/50000, RUY ALBERTO LEME CAVALHEIRO, 27 de julho de 2020.)

Ainda, o c. Superior Tribunal de Justiça:

“Postula, então, a concessão liminar da ordem, a fim de que seja determinado o envio dos autos ao PGJ, nos termos do artigo 28-A, § 14, do Código de Processo Penal (fls. 12/13). (...) Com efeito, esta Corte possui entendimento no sentido de que “Não se pode falar na aplicação do art. 28-A do CPP ao crime de tráfico, uma vez que este não tem pena mínima inferior a 04 anos, um dos requisitos exigidos pelo referido dispositivo (AgRg no AgRg no AREsp n. 1.635.787/SP, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 19/5/2020). Com essas considerações, não tendo, por ora, como configurado constrangimento ilegal passível de ser afastado mediante o deferimento da liminar ora pretendida, indefiro-a” (STJ, HABEAS CORPUS Nº 602131 - SP (2020/0191853-3), MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, 12 de agosto de 2020.)

No mesmo sentido, o c. Supremo Tribunal Federal:

“Se o investigado assim o requerer, o Juízo deverá remeter o caso ao órgão superior do Ministério Público, quando houver recusa por parte do representante no primeiro grau em propor o acordo de não persecução penal, salvo manifesta inadmissibilidade” (HC 194677, Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 11.05.2021).

Assim, o requerimento, desprovido de alguma utilidade, não pode ser acolhido.

No mérito, a acusação procede.

A materialidade está demonstrada pelo auto de prisão em flagrante (fl. 01), boletim de ocorrência (fls. 05-7), auto de exibição e apreensão (fls. 08-9), laudo de constatação (fls. 11-3), fotos (fls. 14-6), laudo de exame químico-toxicológico (fls. 66-8), além da prova oral colhida. Comprovou-se a autoria.

Interrogada, em solo policial (fl. 04) e em juízo (mídia digital), a ré manifestou-se.

O policial civil Adilço, na fase administrativa (fl.02), historiou que: (sic) "estava junto com o policial Júlio realizando diligências em cumprimento à Operação Divisa, tendo o apoio de outros policiais, sendo que ao chegarem com a viatura descaracterizada na Rua Fernando Colombo - Viela, 143-A - Mauá/SP, conhecido ponto de tráfico, adentraram em uma das vielas ali existentes, onde observaram a movimentação de pessoas por aproximadamente 10 minutos, momento em que viram que uma mulher desconhecida pegou algo na sacola plástica que segurava e entregou para um indivíduo que se evadiu do local rapidamente; Que, diante disso, o depoente e seu parceiro Júlio entraram pelo fundo da viela, enquanto que os outros policiais adentraram pela frente da viela, sendo que a mulher ao ver a aproximação do depoente e de Júlio, jogou a sacola em um mato ao lado de uma cerca; Que, o depoente e o policial Júlio abordaram a referida mulher identificada como Nayara Lima Sena, porém, não foi realizada revista pessoal nesta por ser mulher; Que ao verificarem o que tinha dentro da sacola que ela jogou no mato, constaram haver 10 (dez) invólucros contendo suposta maconha, 09 (nove) invólucros contendo suposta cocaína e 12 (doze) invólucros contendo suposta pedra de crack e na sua carteira a quantia de R\$ 85,00; Que, ao ser indagada sobre os fatos, Nayara confessou que estava realizando o tráfico de drogas no local, confessando ainda que é seu primeiro dia de traficância e que iria ganhar R\$ 60,00 pelo dia, do horário das 09:00 às 12:00 horas, porém, não informou quem é seu patrão e nem onde o mesmo possa ser localizado; Que, diante de tais fatos, Nayara foi conduzida a esta Unidade Policial junto com as substâncias, sacola e dinheiro, onde foi revistada pela policial civil feminina Ludimila, a qual localizou no bolso de sua bermuda a quantia de R\$ 104,00, totalizando R\$ 189,00 que estava na posse da indiciada".

No mesmo sentido o depoimento do policial Gilberto (fl.03).

Em juízo, o policial Gilberto afirmou que no dia dos fatos estavam fazendo uma operação no local, ponto conhecido de traficância de drogas. Ficaram por um tempo observando em duas equipes, cada equipe ficou em uma ponta da viela. Viram que a acusada entregava alguma coisa para a pessoa, que entregava algo para a ré. Entraram na viela, a acusada percebeu que eram policiais e jogou a sacola por cima da cerca, onde tem um mato próximo. Fizeram a abordagem e encontraram a sacola com a quantia de R\$ 85,00 em dinheiro, além dos entorpecentes. Na Delegacia, em revista pessoal, foi encontrada mais a quantia de R\$ 104,00 no bolso da bermuda da ré. A acusada disse que era o primeiro dia que estava trabalhando no local, ganhava R\$ 60,00 pelo período das 09h às 12h. O policial Adilço estava junto e presenciou os mesmos fatos (mídia digital).

A prova por meio de depoimento de policiais não é desvaliosa, quanto ao actum a que corresponda, pela só condição profissional das testemunhas. Ao revés, estar-se-ia diante de uma acepção processual de pessoas com apoio em predicado genérico. A jurisprudência dos Tribunais é firme no sentido de que não é causa simpliciter de menor credibilidade a circunstância de uma testemunha ser policial. Nessa linha:

"HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. NULIDADE DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. INSUFICIÊNCIA DAS PROVAS DE ACUSAÇÃO. DEPOIMENTOS PRESTADOS EM JUÍZO POR

AUTORIDADES POLICIAIS. VALIDADE. REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. É da jurisprudência desta Suprema Corte a absoluta validade, enquanto instrumento de prova, do depoimento em juízo (assegurado o contraditório, portanto) de autoridade policial que presidiu o inquérito policial ou que presenciou o momento do flagrante. Isto porque a simples condição de ser o depoente autoridade policial não se traduz na sua automática suspeição ou na absoluta imprestabilidade de suas informações." (STF HC 87.662-5/PE Rel. Min. Carlos Ayres Britto j. 05.09.06 DJU 16.02.07).

A quantidade de droga encontrada e as demais circunstâncias da apreensão, tais como a variedade e a forma em que era transportada, além do dinheiro localizado com a acusada, sem comprovação de origem lícita, trazem elementos suficientes de que ela tinha a droga para entrega a terceiros.

Dessa forma, entende-se que o delito de tráfico de drogas está fartamente comprovado.

Passo à fixação da pena.

Atendendo aos ditames do art. 42 da Lei 11.343/06 e do art. 59 do Código Penal, fixo a pena-base no mínimo legal de 05 anos de reclusão e 500 dias-multa.

Na segunda fase, a menoridade da acusada não enseja redução aquém do mínimo legal, nos termos da Súmula 231 do e. Superior Tribunal de Justiça.

Justifica-se a não incidência da atenuante da confissão, não espontânea, em razão de sua inutilidade para o desate da ação penal. Isso porque a confissão de quem foi presa em flagrante, em plena traficância, não tem o intuito de colaborar para a elucidação dos fatos. Não fosse suficiente, o presente decisum sequer referiu-se ao interrogatório da ré, portanto, sem infringência à Súmula 545 do STJ.

Sobre a necessidade da espontaneidade da confissão, decota-se trecho do voto do v. acórdão proferido pelo eminente Desembargador Ricardo Dip, no julgamento da Apelação Ordinária 1.390.581-8:

"Em acréscimo, confissão do acusado, houve. Espontânea, contudo, não; a que houve, tem caráter de provocada.

É válida –recurso de votos precedentes–, é válida, repito, ainda após a controvertida Reforma do Código Penal em 1984, esta lição de Roberto Lyra:

'A espontaneidade da confissão não diz respeito, é claro, à sua prestação, em que seria redundante a referência...' (Comentários ao Código Penal, ed. Forense, Rio de Janeiro, 1958, vol. 2, n. 64).

Não fosse assim, sobejaria a lei, porque, como disse Fragoso, 'se o agente confessa sob pressão policial, fato, aliás, comum, nenhuma atenuante será aplicável' (Lições de Direito Penal, ed. Forense. Rio de Janeiro, 1994, Parte Geral, n. 345).

Na mesma linha, disse Mirabete: 'Não basta a confissão para a configuração da atenuante; é necessário que o agente, arrependido, procure a autoridade para a confissão, já que a lei não fala em ato voluntário, mas em confissão espontânea' (Manual de Direito Penal, ed. Atlas, São Paulo, 1997, vol. 1, 7.5.6).

Diz José Antonio Paganella Boschi, comentando o disposto na alínea d, inc. III, art. 65, CP: 'Foge ao sentido do texto, portanto, reconhecer a atenuante quando o agente é preso em flagrante e não tem como negar as evidências em torno da autoria ou imputar a responsabilidade pelo fato a terceiro. Inconfundíveis confissão espontânea e confissão voluntária' (Das Penas e Seus Critérios de Aplicação, ed. Livraria do Advogado, Porto Alegre, 2002, p. 273).

A espontaneidade da confissão –prevista em lei como qualificação necessária do ato confessional para atuar como causa de atenuação penal– distingue-se da mera voluntariedade da confissão. Não se trata aí do espontâneo como o que procede de um

princípio interno juxta naturam agentis, sine deliberatione (Marcelino Zalba), mas do que (disse Cathrein) procedit a princípio interno –ou seja, sem provocação exterior." (TACRIM-SP –11a Câmara)

Manifestou-se, também, o Supremo Tribunal Federal quanto à incompatibilidade da atenuante da confissão espontânea com a situação de flagrância:

"CONFISSÃO ESPONTÂNEA ATENUANTE. Em se tratando de situação concreta em que ocorrida a prisão em flagrante, em razão do transporte de vultuosa quantidade de droga, descabe cogitar da atenuante da confissão espontânea, no que esta última tem como objetivo colaborar com o Judiciário na elucidação da verdade real". (HC 101.861/MS, rel. Min. Marco Aurélio, 1ª T., j. em 13.04.2011)

No mesmo julgamento, manifestou-se o Min. Luiz Fux: "Eu também entendo que confissão espontânea e flagrante é contradictio in terminis, não dá para conviver; ou confessa voluntariamente ou é preso em flagrante. Não fez favor nenhum à Justiça".

Na mesma direção, precedentes do e. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

"Apelação- Tráfico de entorpecentes - Recurso da defesa- Pedido para que o réu possa recorrer em liberdade prejudicado pelo presente julgamento. Condenação mantida. Apreensão de 20 porções de maconha e 61 porções de cocaína- Conjunto probatório seguro e coeso. Dosimetria fixada com rigor- Pena fixada no mínimo legal - Pedido de compensação entre confissão e reincidência- Inadmissibilidade- Confissão que sequer foi considerada na formação do convencimento do julgador- Redutor do art. 41 da Lei de Drogas- Não cabimento- Delação após prisão em flagrante com tóxico- Ausência de colaboração efetiva. Regime inicial Fechado obrigatório para réu reincidente condenado a corporal superior a quatro anos- Sentença mantida. Recurso improvido." (TJSP, AP 1501244-55.2019.8.26.0540, Rel. Des. José Vítor Teixeira de Freitas, j. 29.06.20).g.n.

"[...] Não assiste razão ao apelante quando pleiteia o benefício da atenuante da confissão espontânea, previsto no artigo 65, III, "d", do Código Penal, pois, no caso de que se trata, a confissão, além de absolutamente prescindível para o desate condenatório, em razão da solidez da prova incriminadora produzida sob o crivo do contraditório, bem revelando hábil manejo de autodefesa para tentada incidência da atenuante genérica do art. 65, III, "d", do Código Penal. Assim, por não espontânea e desacompanhada de arrependimento, não permitiria a diminuição da pena pela atenuante do art. 65, III, "d", do Código Penal. Nesse sentido, "espontânea é aquela confissão em que o agente, independentemente do concurso da autoridade, busca esta para admitir o delito" (Apelação nº 0001496-21.2009.8.26.0270. Colenda 4ª Câmara de Direito Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Rel. Exmo. Des. LUIS SOARES DE MELLO, j. em 26.6.2012). No mesmo sentido: veneranda decisão da Colenda 4ª Câmara de Direito Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, na Apelação nº 0052302-70.2011.8.26.0050. Rel. Exmo. Des. LUIS SOARES DE MELLO, j. em 16.4.2013). Da mesma forma: STF HC. nº 101.861/MS, Rel. Exmo. Min. MARCO AURÉLIO, j. em 13.4.2011). No mesmo sentido: PROVA - CONFISSÃO ESPONTÂNEA E VOLUNTÁRIA - DISTINÇÃO. "Não se pode confundir a confissão espontânea com a confissão voluntária do réu surpreendido em plena execução do delito. Esta é uma declaração movida por uma circunstância de evidência dos fatos, aquela pela mera intenção de declarar a verdade". (Apelação nº 566.425/1, Julgado em 01/02/1990, Col. 1ª Câmara, Rel.: ALBERTO MARINO. RJDTACRIM 5/169)" (TJSP; Apelação Criminal 1501404-12.2021.8.26.0540; Relator (a): Freddy Lourenço Ruiz Costa; Órgão Julgador: 8ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Mauá - 2ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 22/02/2022; Data de Registro: 22/02/2022). g.n.

"(...) Afasta-se o pleito de reconhecimento da atenuante da confissão. Isso porque

Paulo foi preso em flagrante vendendo drogas a um adolescente e outro indivíduo, de modo que sua confissão não foi utilizada para formação da convicção. O flagrante e os depoimentos das testemunhas são suficientes para sustentar sobremaneira o édito condenatório." (TJSP, 4ª Câmara Criminal, Apelação nº 1500902-44.2018.8.26.0616,, rel. Des. Roberto Porto, j. 18.6.2020, V.U.).g.n.

"(...) Ademais, sobreleva registrar que a referida confissão não foi utilizada pelo magistrado sentenciante como elemento de convicção, não incidindo, assim, na hipótese, a Súmula 545 do Superior Tribunal de Justiça. (...) Veja que, para o reconhecimento da finalidade mercantil da droga apreendida com o acusado, o douto juiz não utiliza de sua confissão a esse respeito, mas sim dos demais elementos de convicção colhidos." (TJSP, 4ª Câmara Criminal, Apelação nº 1500646-88.2020.8.26.0630, rel. Des. Camilo Léllis, j. 22.3.2022, V.U.). g.n.

Apelação criminal - Tráfico de drogas - [...] Dosimetria - pena-base justificadamente fixada acima do mínimo legal. Inteligência do art. 42 da Lei de Drogas. Na segunda fase, exasperação decorrente da reincidência. Confissão que não foi considerada na formação do convencimento do julgador. [...] Preliminar rejeitada. Recurso defensivo improvido. "[...] verificando-se que neste caso, não houve qualquer menção ao teor do interrogatório do acusado para a formação do convencimento do douto Julgador para o deslinde desta ação penal, não há como se acolher o pleito de consideração da referida atenuante de pena, nos termos dos abalizados entendimentos jurisprudenciais referidos." (TJSP; Apelação Criminal 1500255-44.2022.8.26.0540; Relator (a): Ely Amioka; Órgão Julgador: 8ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Mauá - 2ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 08/05/2022; Data de Registro: 08/05/2022).

"APELAÇÃO CRIMINAL - Roubo duplamente majorado - Incidência da causa de aumento de pena do emprego de arma de fogo comprovada pela prova pessoal - Desnecessidade de apreensão e perícia da arma usada no roubo. (...) Impossibilidade de reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, porquanto não utilizada para fundamentar a condenação - Aumento único no concurso de causas de aumento de pena contemplado no parágrafo único do artigo 68 do Estatuto Penal que não constitui direito subjetivo, tratando-se de faculdade judicial, que, porém, requer justificativa sobre a fração imposta, como no caso penas e regime prisional fechados mantidos. RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO." (TJSP, Apelação Criminal nº 1500106-76.2021.8.26.0348, Rel. Des. Adilson Paukoski Simoni, j. 12.04.22).

"(...) Não era o caso, outrossim, do reconhecimento da atenuante da confissão, porquanto tenha ela sido parcial (negou o apelante o emprego de arma de fogo), bem como por ser ela refratária à prisão em flagrante. Como bem destacou o MM. Juízo a quo, no decísium, "(...) Justifica-se a não incidência da atenuante da confissão, não espontânea e parcial, em razão de sua inutilidade para o desate da ação penal. Isso porque a confissão de quem foi preso em flagrante, logo após desembarcar do veículo roubado, e buscou falsear a verdade, a fim de atenuar sua responsabilidade, não tem o intuito de colaborar para a elucidação dos fatos." (fls. 148). De mais a mais, ainda que fosse possível seu reconhecimento, nenhuma redução seria feita, pois, como adiantado, já foram as penas bases mantidas no mínimo legal." (TJSP; Apelação Criminal 1502696-32.2021.8.26.0540; Relator (a): Edison Brandão; Órgão Julgador: 4ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Mauá - 2ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 28/06/2022; Data de Registro: 06/07/2022).

CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE ENTORPECENTES (ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06) - APELO DEFENSIVO ALMEJANDO A ABSOLVIÇÃO, COM PLEITOS SUBSIDIÁRIOS DE DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA E ABRANDAMENTO DAS PENAS. [...] TRÁFICO DE DROGAS - AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA COMPROVADAS - DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS REVESTIDOS DE CREDIBILIDADE - QUANTIDADE E VARIEDADES DAS DROGAS, LOCAL DO CRIME, APREENSÃO DE DINHEIRO, CONFISSÃO DO RECORRENTE - INEQUÍVOCA A TRAFICÂNCIA DADAS AS CONDIÇÕES DO FLAGRANTE - CONDENAÇÃO MANTIDA. PENAS - FIXADAS OBSERVADO O REGRAMENTO APLICÁVEL -

INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 42 DA LEI DE DROGAS E 59 DO CÓDIGO PENAL – BASES NO PISO. ADEQUADO O NÃO RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO, UMA VEZ QUE NÃO SERVIU DE FUNDAMENTO PARA A CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAR PENA AQUÉM DO PISO – SÚMULA 231, DO C. STJ. – REDUTOR DESCABIDO NA ESPÉCIE – REGIME PRISIONAL FECHADO INALTERADO – SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE RESTRITIVAS DE DIREITOS DESCABIDOS – RECURSO DESPROVIDO.(TJSP; Apelação Criminal 1502209-62.2021.8.26.0540; Relator (a): Ivana David; Órgão Julgador: 7ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Mauá - 2ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 15/08/2022; Data de Registro: 15/08/2022) g.N.

Não bastasse, o c. Superior Tribunal de Justiça já decidiu, recentemente:

“Agravamento regimental no habeas corpus substitutivo de recurso próprio. Matéria não analisada na apelação. Óbice à inovação em sede de embargos de declaração. Constrangimento ilegal inexistente, Atenuante da confissão espontânea. Súmula n. 545 do Superior Tribunal de Justiça STJ. Édito condenatório apoiado em outros elementos. Não incidência. Precedentes. Agravamento regimental desprovido. 1. [...] 2. Ainda que controverso o fato de que o paciente assumiu a autoria do delito, esse dado não foi utilizado para a formação do convencimento do julgador. Conforme se verifica, a condenação está amparada no testemunho da vítima e dos policiais condutores da prisão, sendo portanto, inviável a redução da reprimenda. Precedentes, 3. Agravamento regimental desprovido (STJ AgRG no HC 648.216/SC, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 08.06.2021, DJe, 15.06.2021).g.n

“A Súmula 545/STJ prevê que a atenuante da confissão espontânea deve ser reconhecida, ainda que tenha sido parcial ou qualificada, seja ela judicial ou extrajudicial, e mesmo que o réu venha a dela se retratar, quando a manifestação for utilizada para fundamentar a sua condenação. Evidenciado que a confissão informal do réu somente foi explicitada na transcrição dos depoimentos dos policiais condutores, não tendo, todavia, sido utilizada em momento algum para embasar a condenação, sequer citada pelo magistrado sentenciante, deve ser afastada a possibilidade de reconhecimento da atenuante do art. 65, III, 'd', do Código Penal” (AgRG no AREsp 1599610/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 06/02/2020).

“No mais, quanto à atenuante da confissão espontânea, verifico que sua aplicação foi devidamente afastada, no caso, pelo Juízo sentenciante, “em razão de sua inutilidade para o desate da ação penal”, tendo o Magistrado pontuado que “a confissão de quem foi preso em flagrante, com imensa quantidade e variedade de drogas, além de apetrechos para a preparação dos entorpecentes, não tem o intuito de colaborar para a elucidação dos fatos, tratando-se de fato prescindível para a condenação” (fl. 54).Nesse contexto, considerando que a confissão do Acusado não foi utilizada pelas instâncias ordinárias como reforço de fundamentação da condenação, não se aplica a Súmula n. 545 desta Corte Superior, segundo a qual “[q]uando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no artigo 65, III, d, do Código Penal” (HC n. 668.711, Ministra Laurita Vaz, DJe de 21/03/2022).

Ainda assim, as penas não poderiam ser conduzidas aquém do mínimo legal, nos termos da Súmula 231 do STJ.

Na última fase, não deve incidir a causa de diminuição prevista no parágrafo 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06. Diante das circunstâncias do delito -presa em flagrante, com considerável quantidade de drogas e três espécies diversas de entorpecentes, notadamente cocaína e crack, em local conhecido como ponto de tráfico, sabidamente dominado por facções criminosas, portanto, sem espaço para “traficantes ocasionais estranhos à organização criminosa”, além de não ter

comprovado de forma mínima o exercício de atividade lícita- parece-me claro o acentuado envolvimento da acusada no comércio de drogas, ou seja, a não ocasionalidade da conduta. Além disso, na data dos fatos a ré respondia a outro processo pela prática do crime de tráfico (cert. fl. 33 -proc 1500734-71.2021).

Nessa linha, posiciona-se o e. Superior Tribunal de Justiça:

"CONSTITUCIONAL. PENAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO EM SUBSTITUIÇÃO A RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO DE DROGAS. RECONHECIMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO "TRÁFICO PRIVILEGIADO" (LEI N. 11.343/2006, ART. 33, § 4º). IMPOSSIBILIDADE. QUANTIDADE E DIVERSIDADE DE DROGAS APREENHIDAS. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. [...] 02. "A diversidade e a quantidade de droga justificam a não aplicação da minorante do tráfico privilegiado" (HC 199.227/SP, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 28/04/2015; HC 315.716/RS, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 26/05/2015; HC 312.452/SP, Rel. Ministro Félix Fischer, Quinta Turma, julgado em 28/04/2015). À luz desses precedentes e da premissa fática estabelecida no acórdão impugnado - o réu "trazia consigo e em momento anterior adquiriu droga, consistentes em 74,4 gramas de maconha, acondicionadas em 54 trouxinhas plásticas, e 36,07 gramas de cocaína, acondicionadas em 26 supositórios plásticos trouxinhas plásticas" -, não há como aplicar a causa de diminuição de pena do 'tráfico privilegiado' (Lei n. 11.343/2006, art. 33, § 4º). 03. Habeas corpus não conhecido"(STJ HC n. 317.721/SP Rel. Min. Newton Trisotto Quinta Turma DJe de 03/08/2015). g.N.

No mesmo sentido o e. Tribunal de Justiça de São Paulo:

"(...) Frise-se, por oportuno, a inaplicabilidade do redutor especial inserto no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, tal como decido monocraticamente. Como cediço, ao editar o mencionado dispositivo legal, o legislador objetivou dar tratamento diferenciado ao traficante ocasional, representado por aquele que não faz do tráfico o seu meio de vida, por merecer menor reprovabilidade e, conseqüentemente, tratamento mais benéfico do que o traficante habitual. Em outras palavras, para a situação do mercador novato de pequena expressão, o chamado "traficante de primeira viagem", como se pode qualificar aquele que possui "estoque" diminuto para negociar durante um curto período e, em regra, suprir o próprio vício é que a lei previu a benesse como forma de abrandar seu maior rigor punitivo. Nessa quadra, a par da primariedade, os elementos angariados aos autos demonstram, à saciedade, que as circunstâncias fáticas, concretamente recolhidas no curso das investigações e comprovadas em Juízo, são inconciliáveis com a traficância ocasional. Isso porque, o réu foi flagrado transportando e guardando exacerbada quantidade de entorpecentes (247 porções de maconha, 406 pinos de cocaína e 438 porções de crack), com naturezas extremamente destrutivas e nocivas, suficiente a atingir inúmeros usuários, de sorte a evidenciar a dedicação às atividades criminosas (narcotraficância). Nem se cogite a ocorrência do intolerável bis in idem, pois a quantidade dos entorpecentes, muito embora sopesada na primeira fase da dosimetria penal, não foi aqui considerada de forma isolada para o afastamento do benefício legal, ao contrário, as circunstâncias fáticas do flagrante policial (o que inclui natureza, quantidade e diversidade dos entorpecentes, situação de fuga à abordagem, em ponto com denúncias reiteradas da traficância), em conjunto, evidenciam dedicação habitual à atividade criminosa, sendo absolutamente implausível o reconhecimento do privilégio." (Apelação Criminal nº 1500603-96.2021.8.26.0540, Rel. Des. CLÁUDIA FONSECA FANUCCHI, j. 13 de dezembro de 2021).

Ainda sobre o redutor previsto no §4º do art. 33 da Lei 11.343/06:

"(...) Cabe salientar que 'a conduta social do agente, o concurso eventual de pessoas, a receptação, os apetrechos relacionados ao tráfico, a quantidade da droga e as situações de maus antecedentes exemplificam situações caracterizadoras de atividades criminosas', para os fins a que alude o citado artigo de lei (STF, RHC nº 94.806, relatora Ministra Cármen Lúcia). Na realidade, a qualificação do agente como pessoa dedicada às atividades criminosas situação que afasta a incidência da causa de diminuição de pena estampada no artigo 33, parágrafo 4º, da Lei nº 11.343/2006 pode vir assentada na prova indiciária, tal como esta se acha definida no artigo 239, do Código de Processo Penal, em atenção ao princípio do livre convencimento motivado (artigo 155, do Código de Processo Penal), não se exigindo prova direta desta circunstância, sob pena de inviabilização da repressão penal a este tipo de delito, dada a dificuldade de se obter uma prova deste tipo (STF, HC nº 101.519, rel. Min. Luiz Fux). Consoante salientado pelo Ministro Luiz Fux, em passagem bastante elucidativa de seu voto, 'os criminosos não circulam com uma 'carteira de identificação de pessoa dedicada a atividades criminosas'. Deveras, na interpretação do § 4º, do artigo 33, da Lei nº 11.343/2006, há que se atentar para o elemento teleológico, na dicção do artigo 5º, da Lei de Introdução ao Código Civil (FRANCISCO AMARAL, Direito Civil, Introdução, Renovar, 12 edição, pp. 88/89; JOSÉ DE OLIVEIRA ASCENSÃO, O Direito, Introdução e Teoria Geral, Renovar, 2ª edição, pp. 430/431), vale dizer, no sentido de que o escopo da lei foi de beneficiar com uma sensível redução da pena aquele agente que pela primeira vez se lança no mundo criminoso, cuja conduta não representa um maior perigo para a coletividade, de sorte que a pena reduzida, ainda que considerada a gravidade do tráfico de entorpecentes, afigura-se suficiente para a ressocialização e reprove suficientemente o comportamento. Essa não é, decididamente, a situação dos réus." (TJSP, Ap nº 1501840-05.2020.8.26.0540, Des. Rel. LAERTE MARRONE, j. 28.04.21).

"PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO INTERNACIONAL DE ENTORPECENTES (ART. 33, CAPUT, C/C ART. 40, I, DA LEI 11.343/2006). CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO §4º DO ART. 33 DA LEI DE DROGAS. AFASTAMENTO PELO JUÍZO SENTENCIANTE E PELO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL. ANÁLISE DA DEDICAÇÃO DO PACIENTE À ATIVIDADE CRIMINOSA OU DE SER INTEGRANTE DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. NECESSIDADE DO REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. REDISCUSSÃO DE CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. AUSÊNCIA DE ARBITRARIEDADES NO ACÓRDÃO DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ORDEM DENEGADA. 1. A causa especial de diminuição de pena prevista no §4º do artigo 33 da lei 11.343/06 está condicionada ao preenchimento, cumulativo, dos requisitos legais: primariedade, bons antecedentes e agente que não se dedique a atividades criminosas nem integre organização criminosa. [...] 3. A conduta social do réu, o concurso de agentes, a quantidade e a natureza do entorpecente, os apetrechos utilizados e as circunstâncias em que a droga foi apreendida podem constituir o amparo probatório para o magistrado reconhecer a dedicação do réu à atividade criminosa. Precedentes: RHC 94.806/PR, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 16/04/2010; HC 116.541/ES, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 6/6/2013; HC 98.366/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 5/2/2010. [...]" (STF HC 121.057/SP Rel. Min. Luiz Fux j. 25.02.14 DJU 18.03.14).

"HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. MINORANTE DO §4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. QUANTIDADE E VARIEDADE DA DROGA, MAUS ANTECEDENTES E DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. INAPLICABILIDADE DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO. PRESUNÇÃO HOMINIS. POSSIBILIDADE. INDÍCIOS. APTIDÃO PARA LASTREAR DECRETO CONDENATÓRIO. SISTEMA DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. REAPRECIÇÃO DE PROVAS. DESCABIMENTO NA VIA ELEITA. ELEVADA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. CIRCUNSTÂNCIA APTA A AFASTAR A MINORANTE PREVISTA NO ART. 33, §4º, DA LEI Nº 11.343/06, ANTE A DEDICAÇÃO DO AGENTE A ATIVIDADES CRIMINOSAS. ORDEM DENEGADA. 1. O §4º do artigo 33 da Lei de Entorpecentes dispõe a respeito da causa de diminuição da pena nas frações de 1/6 a 2/3 e arrola os requisitos necessários para tanto: primariedade, bons antecedentes, não dedicação à atividades criminosas e não à organização criminosa. 2.

Consectariamente, ainda que se tratasse de presunção de que o paciente é dedicado à atividade criminosa, esse elemento probatório seria passível de ser utilizado mercê de, como visto, haver elementos fáticos conducentes a conclusão de que o paciente era dado à atividade delituosa. 3. O princípio processual penal do favor rei não ilide a possibilidade de utilização de presunções 'hominis' ou 'facti', pelo juiz, para decidir sobre a procedência do 'ius puniendi', máxime porque o Código de Processo Penal prevê expressamente a prova indiciária, definindo-a no art. 239 como 'a circunstância conhecida e provada, que, tendo relação com o fato, autorize, por indução, concluir-se a existência de outra ou outras circunstâncias'. Doutrina (LEONE, Giovanni. Trattato di Diritto Processuale Penale. v. II. Napoli: Casa Editrice Dott. Eugênio Jovene, 1961. p. 161-162). Precedente (HC 96062, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 06/10/2009, DJe-213 DIVULG 12-11-2009 PUBLIC 13-11-2009 EMENT VOL-02382-02 PP-00336). 4. Deveras, o julgador pode, mediante um fato devidamente provado que não constitui elemento do tipo penal, utilizando raciocínio engendrado com supedâneo nas suas experiências empíricas, concluir pela ocorrência de circunstância relevante para a qualificação penal da conduta. 5. A criminalidade dedicada ao tráfico de drogas organiza-se em sistema altamente complexo, motivo pelo qual a exigência de prova direta da dedicação a esse tipo de atividade, além de violar o sistema do livre convencimento motivado previsto no art. 155 do CPP e no art. 93, IX, da Carta Magna, praticamente impossibilita a efetividade da repressão a essa espécie delitiva. 6. O juízo de origem procedeu a atividade intelectual irrepreensível, porquanto a apreensão de grande quantidade de droga é fato que permite concluir, mediante raciocínio dedutivo, pela dedicação do agente a atividades delitivas, sendo certo que, além disso, outras circunstâncias motivaram o afastamento da minorante. 7. In casu, o Juízo de origem ponderou a quantidade e a variedade das drogas apreendidas (1,82g de cocaína pura, 8,35g de crack e 20,18g de maconha), destacando a forma como estavam acondicionadas, o local em que o paciente foi preso em flagrante (bar de fachada que, na verdade, era ponto de tráfico de entorpecentes), e os péssimos antecedentes criminais, circunstâncias concretas obstativas da aplicação da referida minorante. 8. Ordem denegada." (STF HC 111.666/MG Rel. Min. Luiz Fux j. 08.05.12 DJU 23.05.12).

"HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE POR TRÁFICO DE DROGAS. LIBERDADE PROVISÓRIA: INADMISSIBILIDADE. DECISÃO QUE MANTEVE A PRISÃO. PARTICIPAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO VOLTADA PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES E GRANDE QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA: CIRCUNSTÂNCIAS SUFICIENTES PARA A MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO ART. 33, §4º, DA LEI N. 11.343/06 E DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA: IMPROCEDÊNCIA. REDUÇÃO DA PENA INVIÁVEL NA VIA ESTREITA DO HABEAS CORPUS. ORDEM DENEGADA. [...] 6. Os fatos que deram ensejo à não aplicação da causa de diminuição de pena prevista na Lei de Tóxicos são hígidos e suficientes para atestar a dedicação do Paciente às atividades criminosas. 7. A conduta social do agente, o concurso eventual de pessoas, a receptação, os apetrechos relacionados ao tráfico, a quantidade de droga e as situações de maus antecedentes exemplificam situações caracterizadoras de atividades criminosas. [...] (STF HC 109.236/SP Rel. Min. Cármen Lúcia j. 13.12.11 DJU 14.23.12).

Estabiliza-se, assim, as sanções em 05 anos de reclusão e 500 dias-multa.

O valor de cada dia-multa foi estabelecido no mínimo ante a ausência de dados nos autos quanto à situação econômica da ré.

Anote-se que o plenário do Supremo Tribunal Federal declarou inconstitucional o art. 44 da Lei 11.343/06, nas partes em que se vedava a concessão de liberdade provisória (HC n. 104.339, rel. Min. Gilmar Mendes) e a conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos (HC n. 97.256, rel. Min. Ayres Britto), bem como do parágrafo 1º do art. 2º da Lei n. 8072/90, que impunha o regime inicial fechado (HC n 111.849, rel. Min. Dias Toffoli).

Todavia, a gravidade in concreto do delito, considerando a quantidade e diversidade das drogas, assim como o alto potencial lesivo da cocaína e do crack para a saúde pública, indica um grau acentuado de culpabilidade, de forma que o regime inicial fechado mostra-se necessário para o cumprimento da pena privativa de liberdade. Assim já decidiu o Supremo Tribunal Federal:

“HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. NATUREZA E QUANTIDADE DO ENTORPECENTE COMO FUNDAMENTO PARA FIXAÇÃO DO REGIME PRISIONAL INICIAL E PARA A NÃO SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. ORDEM DENEGADA. Possibilidade de fixar regime inicial fechado e de afastar a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos com base na quantidade e na natureza do entorpecente apreendido. Precedentes. Ordem denegada.” (STF – HC 119.515/AC – Rel. Min. Cármen Lúcia – j. 03.12. – DJU 10.12.13)

Pelo mesmo motivo, não é hipótese de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, insuficiente para prevenção e reprovação da conduta.

Posto isso, julgo PROCEDENTE o pedido formulado na ação penal para